

1502699-52.2021.8.26.0292

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... com droga em mãos. Não realizava o tráfico de drogas naquela oportunidade. Em juízo,

A testemunha BRUNO FREITAS DOS SANTOS PEREIRA, Guarda Municipal, em solo policial, declarou que estavam em ronda rotineira pelo bairro denominado Jardim da Conquista, no Parque Meia Lua, local conhecido por ter alto índice de tráfico de drogas, quando dois indivíduos desconhecidos ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502699-52.2021.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502699-52.2021.8.26.0292

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2311815/2021 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 15636624 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 1683/21/515

- DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2311815 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI DE OLIVEIRA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.VANDERLEI DE OLIVEIRA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 20h42min, na Rua Quatro, 20, Lagoa Azul, Jacareí- SP, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 18 (dezoito) microtubos contendo a droga ADB-

BUTINACA (S)-N-(1- amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide), constante na lista F2, item b (classes estruturais dos canabinoides sintéticos), subitem 6 (estrutura 9), da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), com massa líquida total de 4,1 gramas, drogas as quais causam dependência física e psíquica, tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 23/26 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 37/39.

A denúncia foi oferecida em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 42/49).

Após a apresentação da defesa preliminar (fls. 66/67) a denúncia foi recebida no dia 30 de maio de 2022 (fls. 70/73).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a absolvição do réu por falta de provas. No mesmo sentido a manifestação da Douta Defesa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está substanciada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/07), Exibição e Apreensão (fls. 08), Laudo de Constatação Prévia de Substância Tóxica (fls. 23/26), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 37/39), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes.

O réu VANDERLEI DE OLIVEIRA PEREIRA, interrogado em solo policial, declarou que na data dos fatos estava no final da rua da sua casa com o vizinho Jorginho e foram beber uma cerveja. Após isso foi até o final da rua da casa de sua avó, pelo pasto, momento até que foi advertido por sua mãe para não ficar na rua para não arrumar problema. Informou sua genitora que não teria medo, pois não estava fazendo nada de errado. Quando chegou lá viu que seu tio não estava na casa de sua avó e, ainda, percebeu que os meninos que ficam traficando na região haviam corrido da viatura da guarda. Assim, ao retornar para sua casa, foi abordado pelos GCM's, mas não fugiu da abordagem por não fazer nada de errado. Não viu nenhum guarda municipal achando droga e não indiciou nenhum lugar onde tinha droga aos agentes municipais. Após isso veio conduzido ao distrito policial. Em juízo, ao ser interrogado, o réu negou o crime, aduzindo que estava acompanhado do seu tio e de um vizinho tomando uma cerveja. De repente os meninos passaram correndo. Acabou sendo abordado pelos Guardas Municipais. Atualmente tem 24 anos de idade. Reside em Jacareí. Trabalha com montagem de evento. Tem uma filha. Nunca foi preso ou processado anteriormente.

A testemunha GUILHERME FABRICIO DOS SANTOS aduziu em solo policial, na presença de sua genitora, que na data dos fatos estava embaixo da árvore situada na esquina de sua casa (rua três) quando viu viaturas da guarda municipal passar. Quando foi até a Rua um chamar seu primo para ir comer, este estava no parquinho. Ao retornar para a rua de sua residência foi abordado pelo Guarda Municipal. Após receber ordem de parada não correu e permaneceu parado com braços levantados. Quando foi abordado, os guardas já estavam com uma sacola com droga em mãos. Não realizava o tráfico de drogas naquela oportunidade. Em juízo,

A testemunha BRUNO FREITAS DOS SANTOS PEREIRA, Guarda Municipal, em solo policial, declarou que estavam em ronda rotineira pelo bairro denominado Jardim da Conquista, no Parque Meia Lua, local conhecido por ter alto índice de tráfico de drogas, quando dois indivíduos desconhecidos ao avistarem a viatura oficial da Guarda,

empreenderam fuga, devido a atitude de ambos, foram ao encalço dos mesmos, conseguindo deter o adolescente identificado por Guilherme Fabricio dos Santos na Praça Vicente Mazzeo s/nº, e o acusado na Rua Quatro (Rua Valdo Luiz Davila Mercadante), próximo ao número 59. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com ambos. Indagado informalmente o acusado admitiu que estava realizando o tráfico de drogas no local, apontando uma árvore na Rua Quatro, onde escondia a droga e o dinheiro. O adolescente não falou nada. O acusado e o menor foram conduzidos ao Distrito Policial. Não presenciou qualquer ato de traficância por parte do acusado. Em poder do acusado nada de ilícito foi encontrado.

No mesmo sentido o depoimento do Guarda Municipal RODOLFO PIRES FORONI, que participou da prisão em flagrante do réu. Aduziu que não havia qualquer denúncia anônima noticiando o tráfico de drogas. Realizavam um patrulhamento rotineiro na ocasião quando os quatro indivíduos correram. Chamou a atenção da GCM o fato de os indivíduos terem corrido quando avistaram a viatura e, ainda, por ser o local ponto de venda de drogas. Não presenciou qualquer ato de venda de drogas.

Pois bem.

As provas produzidas são insuficientes para o decreto condenatório.

De início anoto, como bem salientou a Dra. Promotora de Justiça, que a prova amealhada durante o inquérito policial não foi repetida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nenhuma porção de droga foi apreendida em poder do acusado.

E os Guardas Municipais não apresentaram qualquer elemento concreto que pudesse ligar o acusado às substâncias entorpecentes apreendidas.

Mas não paramos por aí.

Prescreve o artigo 301, do Código de Processo Penal: "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

No caso em tela o réu foi abordado pelos Guardas Municipais porque teria corrido juntamente com outros indivíduos em local que seria conhecido por ser ponto de venda de drogas. Com ele, nos termos acima expostos, nada foi apreendido.

A prova obtida para imputação ao réu do delito de tráfico de drogas contém manifesta ilegalidade.

Os Guardas Municipais infringiram e muito o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, que estabelece: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei".

No mesmo artigo 144, § 5º, da Carta Magna é determinada a competência da Polícia Militar para o policiamento ostensivo.

Neste diapasão parece evidente que cabe à Polícia Militar exercer o patrulhamento ostensivo e à Polícia Civil exercer o papel investigativo, cabendo tão somente à Guarda Municipal a proteção de bens, serviços e instalações públicos.

Não poderiam os Guardas Municipais efetuar diligências para investigar e prender um determinado traficante. A conduta que era de se esperar no caso em tela era o acionamento da Polícia Militar ou da Polícia Civil pelos GCMS.

Não havia estado de flagrância como, aliás, aduziram os GCMs em seus depoimentos. Afinal, o réu não trazia qualquer sacola na mão ou possuía volume no bolso. E nenhum ato de venda de droga foi presenciado para justificar a prisão.

Extrapolaram e muito os Guardas Municipais as atribuições constitucionais que lhe são conferidas, que afastam qualquer possibilidade de investigação para detenção de um determinado criminoso.

Outrossim, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já enfrentou em diversas oportunidades este tema e vem decidindo pela ilegalidade da conduta de Guardas Municipais que realizam diligências investigativas para prender um determinado traficante.

Nesse sentido: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca e apreensão. Guarda Municipal. Atividade policial. Guardas civis não são porque não devem mesmo ser policiais. Nossa ordem constitucional e legal é claríssima nesse sentido. Compete às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, o exercício da atividade de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, assim como compete às polícias militares a atividade de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 4º e 5º). Nesse sentido, prossegue o constituinte, as guardas municipais, constituídas pelos Municípios, estão nada mais que simplesmente destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 8º). Assim, se porventura a Guarda Municipal receber informações que determinado veículo carregaria drogas, deve repassá-las de imediato à Polícia Civil ou à Polícia Militar que, do alto de sua competência constitucional e legal, poderão, se o caso, tomar as providências devidas. Não podem os guardas municipais, sob o argumento de dispor de tais informações ou denúncias anônimas, procurar por veículos na cidade e, avistando-os, determinar ao condutor respectivo? embora sem certeza visual alguma de crime, o que aí sim poderia ensejar a atuação de qualquer um do povo a parada imediata, sujeitando, como se policiais fossem, seus ocupantes e o próprio carro a procedimento invasivo de revista. Se o fizerem, a prova assim obtida e toda a investigação daí subsequente estarão contaminadas pela ilegalidade” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002974-40.2018.8.26.0079, 2ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Sérgio Mazina Martins, j. 03.06.2019).

Na mesma toada: TJSP, Apelação Criminal nº 0010190-16.2011.8.26.0526, Relator Desembargador Almeida Sampaio.

A atuação da Guarda Municipal não pode envolver patrulhamento ostensivo e judiciário.

A prova é, portanto, ilícita e está maculada. Além de ser extremamente frágil como acima foi exposta.

Finalizando, não posso deixar de salientar que mesmo se a diligência no caso sub judice tivesse sido liderada por policiais militares a prova seria igualmente questionada.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC nº 158.580, cuja relatoria coube ao E. Ministro Rogério Schietti Cruz, decidiu recentemente que a revista pessoal baseada em “atitude suspeita” é ilegal.

É necessária a descrição objetiva e precisa da fundada suspeita, exigida pelo artigo 244, do Código de Processo Penal. E a apreensão de arma e drogas em momento posterior não convalida a busca pessoal.

O mesmo Tribunal Cidadão também decidiu recentemente que a denúncia anônima não justifica busca pessoal e veicular se ela estiver desacompanhada de outros

elementos concretos (HC 734.263, Relator Min. Sebastião Reis Junior).

Ora, se o réu não trazia nada consigo (sacola ou algum objeto na mão) ou possuía volume na cintura, e se nenhum ato de venda de drogas foi presenciado, a abordagem poderia ser colocada em xeque.

Em matéria criminal: “Não estando suficientemente demonstradas as provas da materialidade, autoria e o elemento subjetivo, simples indícios do ilícito não são suficientes para um Juízo de condenação” (TRF, 2ª Região – Ap. – Rel. Alberto Nogueira – RT 725/675).

No mesmo sentido: “É impossível fundar solução condenatória em prova que não conduz a certeza, não bastando a probabilidade, sobre o juízo da existência de certo fato ou mesmo a convicção íntima, sem o concurso de dados objetivos de justificação” (Tacrím – SP – Ap. Rel. Passos de Freitas – RJD 20/176).

Em Direito Penal a prova cabe a quem acusa e não pode ser dirigida a quem se diz inocente. Brilhante a lição de Nicola Framarino Dei Malatesta: “O ordinário do homem é a inocência, por isso ela se presume e é ao acusador que cabe a obrigação da prova no juízo penal.... Mas quando em geral se trata do ônus da prova em juízo penal, fala-se em obrigação de produzi-la como sustentação de uma dada afirmação. Ora, aberto o juízo penal, aí deverá sempre existir a imputação de crime e, por isso, um acusador e um acusado, bem como uma afirmação acusadora e uma eventual afirmação defensiva. A estas duas asserções se refere o problema do ônus da prova, visando estabelecer qual das duas deve provar-se primeiro. Neste caso, não se poderá nunca dizer que a obrigação da prova incumbe ao juiz que deve pronunciar; o juiz, como tal, não afirma nada, deve julgar entre as várias afirmações e provas; é obrigação sua, como juiz, no momento da produção das provas, limitar-se a colher todas as provas que possam conduzir à verdade judicial, fim supremo de todo processo. Não é, portanto, errôneo, o falar de prova relativamente ao acusado e acusador. Voltando ao que dizíamos e concluindo, a inocência se presume. Por isso, no juízo penal, a obrigação da prova cabe à acusação” (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, tradução Paolo Capitanio, ed. Bookseller, 1996, págs. 134 e 136).

Assim, o réu deve ser absolvido do crime que lhe foi imputado na denúncia com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER o réu VANDERLEI DE OLIVEIRA PEREIRA do crime que lhe foi imputado na exordial acusatória, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Oportunamente arquivem-se os autos com as cautela de estilo.

Jacarei, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA